

1517163-33.2021.8.26.0405
Classe: Termo Circunstanciado
Assunto: Contravenções Penais
Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO
Comarca: Osasco
Foro: Foro de Osasco
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 26/04/2022

... bandidos e há outros, como o jogo e o tráfico de drogas, em que as supostas vítimas chegam a fazer fila para ser atendidas pelos delinquentes. É mais fácil reprimir as infrações do primeiro grupo, nas quais a polícia conta com a colaboração da parte lesada, do que as do segundo, que nem sequer são notificadas como crime a esclarecer.

O fato de "vítima" e delinquente estarem do mesmo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Osasco
Foro de Osasco
3ª Vara Criminal
Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

1517163-33.2021.8.26.0405 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1517163-33.2021.8.26.0405
Classe - Assunto
Termo Circunstanciado - Contravenções Penais
Autor:
Justiça Pública
Autor do Fato:
LUCAS FAZOLIN

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

LUCAS FAZOLIN, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 50, do Decreto-Lei 3.688/1941, porque no dia 08 de dezembro de 2021, por volta de 17h15, dentro de estabelecimento comercial, que é de acesso público, sito na Avenida dos Autonomistas, 4849, Km Dezoito, neste município e Comarca, explorava jogo de azar, pois mantinha em funcionamento duas máquinas de jogo eletrônico tipo caça-níquel, nas quais o ganho e a perda dependiam exclusiva ou principalmente da sorte, conforme atesta o laudo pericial de fls. 22/24.

É a síntese do necessário.

D E C I D O.

A denúncia não pode ser recebida.

O direito penal é composto pelos princípios da adequação social, insignificância, ofensividade, proporcionalidade, subsidiariedade e fragmentariedade, devendo ser a ultima ratio no trato dos problemas sociais.

A exploração do Jogo de Azar era permitida no Brasil até 1976. Sua proibição foi estabelecida por força do Decreto-Lei 9.215/46, sob o argumento de que o jogo é degradante para o ser humano.

No entanto, a Constituição Federal vigente, em seu artigo 22, inciso XX, confere poder à União para legislar sobre sistema de consórcios e sorteios, detendo, assim, competência exclusiva para legislar e usufruir em benefício próprio, e vedando à iniciativa privada o exercício deste direito.

Fato é que as consequências dessas atividades advêm da própria ilicitude imposta. No entanto, se tal exploração vicia a população, se leva as famílias a miséria, porque a vedação não ocorre também em relação ao Estado? Por que o Estado pode lucrar com jogos (loterias) e a iniciativa privada não?

O efeito nocivo do jogo, se existente, ocorre tanto quando o jogo é explorado pela iniciativa privada, como quando o jogo é explorado pela União, que, diga-se, vem se esmerando em criar cada vez novas modalidades de jogos ou apostas, sendo que somente na modalidade esportiva podem ser citadas a Lotomania, Quina, Quadra, Loteca, Lotogol, Sena, Dupla Sena, Loto, Mega-sena, etc.

Nesse sentido, confira-se a opinião de Hélio Scharfman, colunista da Folha de São Paulo:

“Bicho, corrupção e liberdade.

SÃO PAULO – Sempre vem à tona um caso glamoroso de corrupção envolvendo bicheiros e políticos, surgem aqueles que advogam pela legalização do jogo no Brasil. Incluo-me nessa categoria, não por solidarizar-me com bicheiros ou políticos, mas por crer em liberdades.

Existem dois tipos de crimes. Há aqueles – a esmagadora maioria, em que a parte ofendida não concorda com ação dos bandidos e há outros, como o jogo e o tráfico de drogas, em que as supostas vítimas chegam a fazer fila para ser atendidas pelos delinquentes. É mais fácil reprimir as infrações do primeiro grupo, nas quais a polícia conta com a colaboração da parte lesada, do que as do segundo, que nem sequer são notificadas como crime a esclarecer.

O fato de “vítima” e delinquente estarem do mesmo lado significa lucros fáceis, os quais tendem a organizar-se em torno de estruturas criminosas hierarquizadas, que não hesitam em utilizar parte dos recursos para corromper autoridades.

É claro que a dificuldade de reprimir não é, por si só, um argumento para que desistamos de fazê-lo. A investigação de homicídios também é complicada, mas nem por isso devemos legalizar assassinatos. Ocorre que os criminosos relacionados a jogo e drogas, além da anuência da dita vítima, apresentam outra especificidade: o mal resultante da ação fica circunscrito à própria pessoa (torrar todo o patrimônio num cassino) ou está dentro dos limites discricionários facultados a cada indivíduo (ficar doente por não cuidar da saúde).

E não faz muito sentido colocar a polícia para proteger “manu militari” o cidadão de si mesmo. Democracias conferem às pessoas também o direito de tomar decisões erradas.

Legalizar jogo e drogas não implica abandonar ludopatas e dependentes à própria sorte. O Estado pode apoiá-los com programas de prevenção e tratamento. Não são uma maravilha em termos de eficácia, mas a repressão tampouco o é.”

(Folha de S. Paulo, 25.02.2012, A3).

Ademais, não há como ignorar que o jogo de azar é amplamente aceito socialmente. Há projetos de lei em andamento no Governo Federal visando regularizar a prática desses jogos. Argumentam que a legalização irá gerar emprego, diminuir a corrupção e aumentará a coleta dos impostos.

Seja como for, o que não se mostra possível é aderirmos a um discurso de ofensividade, proporcionalidade, subsidiariedade, fragmentariedade, ultima ratio e,

de outro lado, mantermos práticas absolutamente contraditórias no dia-a-dia da Justiça Criminal.

Nesse sentido, segue voto da relatora do Tribunal do Rio Grande do Sul, Juíza Ângela Maria Silveira:

APELAÇÃO CRIME. CONTRAÇÃO PENAL. JOGOS DE AZAR. ART. 50, DO DECRETO-LEI Nº 3688/1941. EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS ELETRONICAMENTE PROGRAMÁVEIS. MONOPÓLIO DO JOGO PELO ESTADO. Sistema de loterias no Brasil. Se a exploração do jogo causa efeitos sociais nefastos, se o jogo pode viciar, se o jogo propicia a exploração de estrato carente da população e, por estes e outros fundamentos, é moralmente reprovável e, por isto, deve ser coibido, a vedação deve ocorrer tanto em relação à iniciativa privada como em relação ao Estado. Não se pode conceber que eventual ofensa a bem jurídico tutelado ocorra somente quando a atividade seja explorada pela iniciativa privada e negar que ocorra ofensa ao mesmo bem jurídico, quando a atividade é explorada pelo Estado. A exploração comercial ou empresarial de máquinas eletronicamente programáveis ou caça-níqueis, não se constituindo em loteria, strito sensu, não configura a contração de jogo de azar. PROVIMENTO DA APELAÇÃO. (Recurso Crime |TURMA RECURSAL CRIMINAL| Nº 71002606457 |COMARCA DE TAPEJARA| ENIO ZANATTA |RECORRENTE |MINISTÉRIO PÚBLICO |RECORRIDO).

Não se pode conceber que eventual ofensa a bem jurídico tutelado ocorra somente quando a atividade seja explorada pela iniciativa privada e negar que ocorra ofensa ao mesmo bem jurídico, quando a atividade é explorada pelo Estado.

Pode-se objetar que a exploração do jogo pela iniciativa privada possibilite lavagem de dinheiro e/ou exploração pelo crime organizado, porém isto é hipótese, que, ocorrendo, será reprimida, tal como, presume-se, deva ocorrer quando envolve o poder público.

A tipificação do delito deve ter interpretação restrita e não ampliativa, observados os termos do artigo 1º, do Código Penal Brasileiro, pelo qual não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.

Ainda que assim não se entenda, para a caracterização da contração penal em tela, é necessária a comprovação do efetivo emprego do equipamento para exploração do jogo de azar, já que o tipo exige, para a configuração do ilícito, habitualidade, intenção de lucro e efetiva disponibilização do maquinário para uso de terceiros.

Em suas declarações, o denunciado disse que é porteiro do local e que ali funciona uma casa noturna. Informou que existem duas máquinas caça-níquel, e no momento da chegada dos policiais uma estava ligada e não haviam apostadores no local. Esclarece que as máquinas "apareceram" há cerca de duas semanas, não sabendo informar quem as instalou no local. Aduziu que recebe R\$ 50,00 por dia e que não conhece o responsável pelo estabelecimento.

Não houve comprovação de que o denunciado é o responsável pelo estabelecimento comercial, tampouco que estivesse explorando com habitualidade o jogo de azar no estabelecimento comercial indicado na denúncia. A habitualidade verifica-se quando o uso da máquina se dá de forma frequente, costumeira e repetida, o que não se comprovou no caso em apreço.

Dessa forma, sendo certo que a posse de máquinas caça- níqueis por si só não caracteriza a contração penal, de rigor a rejeição da denúncia.

Neste sentido:

A contração do art. 50 da lei especial exige a prova de habitualidade da

conduta, ao seu reconhecimento (TACRIM-SP-AC-Rel. Rafael Granato - JUTACRIM - 43/340)

Contravenção penal - Jogo de azar - Prova de habitualidade - Indispensabilidade - A contravenção de jogo de azar exige sempre habitualidade (TACRIM-SP-HC-Rel. Camargo Sampaio-JUTACRIM 73/393)

Em decorrência, REJEITO A DENÚNCIA ofertada contra LUCAS FAZOLIN, qualificado nos autos, da acusação da contravenção prevista no artigo 50, do Decreto-Lei 3.688/1941, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Osasco, 08 de abril de 2022.